

1500383-31.2022.8.26.0648

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... a existência de diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas.

Consta do referido laudo (fl. 180) que: "Tal análise se deu por amostragem considerando a carga imensa de assuntos relacionados ao tráfico de drogas e os recursos humanos disponíveis nesta Unidade Policial, fora observados os seguintes diálogos:".

Em relação ao caderno apreendido entre os pertences do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500383-31.2022.8.26.0648 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500383-31.2022.8.26.0648

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO PORFÍRIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1500383-31.2022.8.26.0648

Vistos.

GUSTAVO PORFÍRIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 05 de julho de 2022, por volta das 12h30min., na Rua Servidor José Crisostemo, 290, Recanto Azul, no município de Irapuã e Comarca de Urupês, o denunciado teria guardado 03 porções de crack, com peso bruto aproximado de 1,7g, e 01 porção de cocaína com peso bruto aproximado de 4,9g, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e foi recebida no dia 06 de julho de 2022 (fls. 69/72) em audiência de custódia, oportunidade que o réu também foi pessoalmente citado.

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em memoriais (fls. 201/210), o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez

(fls. 225/236), sustentou, preliminarmente, a ilicitude da prova decorrente da prisão em flagrante, por mácula à inviolabilidade de domicílio. No mérito, quanto ao crime de tráfico, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 e pela aplicação ao caso da causa de diminuição de pena veiculada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

A preliminar invocada pela aguerrida defesa não comporta acolhimento, não padecendo de qualquer nulidade a prova decorrente da busca domiciliar narrada na inicial acusatória.

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, expressamente excepciona o direito à inviolabilidade de domicílio para os casos de flagrante delito. Tratando-se o tráfico em infração de natureza permanente, afigura-se prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada do agente durante o iter criminis. Nesse ponto, não se desconhece o recente entendimento do C. STJ sobre a necessidade de autorização formal dos moradores para entrada dos policiais na residência. Contudo, o entendimento acima mencionado não se aplica ao caso em análise (distinguish), em razão das divergências que seguem abaixo detalhadas.

Aqui, vale destacar que os policiais foram até a residência do denunciado a fim de conduzi-lo coercitivamente ao gabinete da 13ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto, no entanto, na oportunidade, o réu foi encontrado no banheiro da residência acionando, reiteradamente, a descarga do vaso sanitário.

É evidente que tal fato caracterizou a justa causa para revista dos policiais no banheiro, sendo que lograram êxito em encontrar 03 porções de crack no vaso sanitário. Assim, em que pese a insistência da D. Defesa, não há que se falar em nulidade da prova colhida no local e, tampouco, de ausência de justa causa para ação penal.

Quanto ao mérito, iniciando as necessárias perquirições pela imputação referente à prática do tráfico, observo, nesse particular, que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 14/15), laudo de exame químico toxicológico (fls. 136/139), laudos periciais (fls. 95/99 e 162/171), relatório de investigações (fls. 180/189), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Guilherme Garbui, policial militar, declarou que foram até o local para cumprimento de uma condução coercitiva proveniente da 13ª Promotoria de São José do Rio Preto. Ao chegar no local, bateram palmas e a mãe de Gustavo o alertou que os policiais estavam no local. Disse que avistaram, através de uma porta de vidro, "correria" no interior da residência. Em seguida, a genitora de Gustavo abriu a porta e foi cientificada da condução coercitiva. Na oportunidade, os policiais ouviram diversas descargas no banheiro e foram até o local. Relatou que o Cabo Adriano conseguiu recuperar três porções de crack. Em revista no imóvel, no quarto do acusado, foi encontrada uma pedra bruta de cocaína e um aparelho de telefone celular. Informou que o réu já era conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico, em razão da existência de diversas denúncias em seu desfavor, motivo pelo qual foi dada voz de prisão. Narrou que foi apreendido um telefone celular durante a diligência, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que o aparelho apreendido pertencia à genitora do acusado. Esclareceu que também encontraram na residência um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Disse que, em outubro de 2021, o declarante foi até a residência do adolescente para o cumprimento de um mandado de internação, oportunidade que também encontraram drogas no imóvel. Afirmou que residem no imóvel os genitores e um irmão de Gustavo.

A testemunha Adriano José Gonçalves, policial militar, narrou que foram solicitados para apoiar uma condução coercitiva de Gustavo, expedida pela Comarca de São José do Rio Preto. Disse que se deslocaram até a residência do acusado, acompanhado de

outras equipes e, ao chegar na residência chamaram pelo acusado. Na oportunidade, ouviram movimentação no interior da residência e diversas descargas no banheiro. Assim que Gustavo saiu do banheiro, o declarante foi até o local e abordou o acusado. Ato contínuo, o declarante entrou no banheiro e localizou 03 porções de crack, que, provavelmente, não desceram com as descargas. No quarto do acusado foi encontrada uma porção bruta de cocaína, com peso aproximado de 05 gramas, além de dinheiro e um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico. Inicialmente, Gustavo negou a existência de entorpecentes na residência, porém, após a localização da droga o réu afirmou que era usuário. Esclareceu que o réu era conhecido nos meios policiais e havia saído recentemente da fundação CASA. Informou que entraram no domicílio em cumprimento ao mandado de condução coercitiva, momento que foram recebidos pelos genitores do acusado que liberaram a entrada dos policiais, sendo que Gustavo foi abordado logo após sair do banheiro. Nesse quadro, na esteira de entendimento corrente, cumpre enfatizar que o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira sobre as testemunhas, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade. Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais. Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0094524-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016);

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). (HC n. 477.171/SP,

relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Valdir Porfírio da Silva, genitor do acusado, ouvido na condição de informante, contou que estava na residência no momento da abordagem e prisão de Gustavo. Disse que estava em sua residência quando os policiais invadiram a residência e afirmou que eles não apresentaram nenhum documento. Afirmou que os policiais abordaram Gustavo, porém o declarante não tem conhecimento sobre a existência de drogas na residência. Indagado, esclareceu que o caderno apreendido na residência era de sua propriedade e continha anotações relacionadas a venda de leite que o declarante efetuava. Relatou que o dinheiro apreendido era de propriedade do declarante e estava com o acusado para que ele comprasse uma pomada. Afirmou que o réu estava trabalhando com o declarante no cultivo de seringueira. Mencionou que os policiais invadiram a residência e não apresentaram qualquer justificativa. Declarou que tinha o conhecimento sobre uma audiência futura na Comarca de São José do Rio Preto, porém não foram intimados para comparecer à audiência. Narrou que Gustavo foi internado na fundação CASA, mas não soube indicar precisamente o motivo da internação. Afirmou que Gustavo não estava com nenhum problema estomacal/intestinal na manhã dos fatos.

Aparecido Augusto Vieira, ouvido na condição de informante, afirmou que comprava leite do Sr. Valdir e que o declarante era conhecido por "Cidão", bem como que havia outro indivíduo que também comprava leite de Valdir, este, conhecido por "Toinho". Sobre o acusado, não tem conhecimento de nenhum fato negativo.

Maria de Lourdes Oliveira dos Santos, ouvida na condição de informante, confirmou que Valdir, genitor do acusado, vendia leite na vizinhança. Afirmou que comprava leite de Valdir, bem como que outras pessoas também compravam, tais como "Toinho", Rita, Daiane. Narrou que as vendas eram realizadas para pagamento posterior. Disse que o acusado trabalhava com seu genitor na seringueira.

O réu, interrogado em juízo, sustentou que a droga apreendida em sua residência seria destinada ao seu consumo. Afirmou que estava trabalhando à época de sua prisão e não havia necessidade de praticar o tráfico, pois exercia emprego lícito. Indagado, afirmou que jogou a droga no vaso sanitário, porém não conseguir dar a descarga. Confirmou que, na data de sua prisão, veio até a promotoria de Urupês para prestar depoimento relacionado a fatos ocorridos enquanto esteve internado na fundação CASA. Disse que os policiais não exibiram qualquer documento ou mandado quando entraram em sua residência. Negou a propriedade do caderno que foi apreendido em seu quarto e afirmou que o celular apreendido pertencia à sua genitora, porém era utilizado também pelo declarante, que justificou estar sem telefone celular.

Logo, não há dúvidas que o réu fora efetivamente surpreendido guardando os entorpecentes, conduta que se amolda ao tipo imputado.

A versão dos fatos apresentada pelo acusado em seu interrogatório restou isolada das provas colhidas sob o crivo do contraditório, pois devidamente comprovada a propriedade dos entorpecentes apreendidos na residência do acusado, bem como que seriam destinados ao consumo de terceiros. .

Na data dos fatos, os policiais foram até a residência de Gustavo, com o objetivo de conduzi-lo coercitivamente para ser ouvido perante o Ministério Público da Comarca de São José do Rio Preto.

Contudo, assim que avistou os policiais, a genitora do acusado o avisou sobre a presença dos militares na residência e iniciou uma movimentação suspeita no interior do imóvel. Os policiais foram recebidos pelos genitores de Gustavo, enquanto o réu estava no interior do banheiro acionando a descarga do vaso sanitário reiteradamente. Ao sair do banheiro, Gustavo foi abordado pelos policiais que, imediatamente, vistoriaram o vaso sanitário e encontraram as porções de crack apreendidas.

Portanto, a versão sustentada pela D. Defesa e pelo genitor do acusado, no sentido de que os policiais entraram de surpresa e sem qualquer motivo no imóvel é completamente inverossímil.

Como bem argumentou o I. Promotor de Justiça, caso a entrada dos policiais no imóvel tivesse ocorrido de forma sorrateira, certamente Gustavo não teria tempo de

entrar no banheiro e dispensar os entorpecentes no vaso sanitário, fato confessado pelo próprio réu em seu interrogatório.

Ademais, a conduta do acusado que tentou se desvencilhar do entorpecente ao notar a presença dos policiais, associada as informações anteriores, recebidas pela equipe policial, indicando a prática de tráfico pelo acusado, constituem elementos concretos para caracterizar a situação de flagrância e justificaram a busca domiciliar no quarto utilizado por Gustavo, onde foi encontrada uma porção grande de cocaína.

Tal porção, encontrava-se na forma bruta, pesando aproximadamente 05 gramas e, após o fracionamento, seria suficiente para atingir grande número de usuários, como afirmado pelo policial militar ouvido em juízo.

Além do mais, o relatório de investigação de fls. 180/189, realizado com base no telefone celular utilizado pelo acusado, apontou a existência de diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas.

Consta do referido laudo (fl. 180) que: "Tal análise se deu por amostragem considerando a carga imensa de assuntos relacionados ao tráfico de drogas e os recursos humanos disponíveis nesta Unidade Policial, fora observados os seguintes diálogos:".

Em relação ao caderno apreendido entre os pertences do acusado, a D. Defesa argumentou que se tratavam de anotações realizadas pelo genitor de Gustavo, Sr. Valdir e seriam relacionadas ao comércio de leite realizado por Valdir. Entretanto, o objeto foi submetido a perícia e o I. Perito constatou que: "As anotações empregadas e encontradas nas peças descritas, embora sem clara indicação do que se referiam, levam a perícia a não descartar a possibilidade de parte delas ser lançamentos relacionados com o tráfico de entorpecente."

Portanto, encontrando-se bem elucidado que a propriedade de todo o entorpecente apreendido realmente deve ser atribuída ao denunciado, o intuito mercantil e, por conseguinte, a traficância, exsurtem evidentes, à luz dos critérios elencados no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Além dos relatos policiais registrando a existência de diversas denúncias anônimas sobre a prática do tráfico pelo réu, observo que a quantidade de substância ilícita arrestada, 03 porções de crack e 01 porção bruta de cocaína, em muito supera aquilo que normalmente se encontra na posse de um simples usuário.

A forma de acondicionamento da droga, parte em porção grande, em forma bruta, e parte em porções pequenas, também indica a posição do réu de fornecedor na cadeia de comercialização do produto ilícito, restando evidente que ele adquire o tóxico em forma bruta e o subdivide em frações individuais para fins de comércio.

Aponta, ainda, para a traficância o fato de o acusado ter em depósito dois tipos diferentes de substâncias ilícitas. Sendo o tráfico um negócio, à evidência, o agente criminoso sempre procura aumentar seu rol de consumidores expondo à venda a maior variedade possível de drogas, atendendo ao gosto de cada usuário.

Por fim, as condições pessoais do increpado também amparam a pretensão punitiva estatal na forma como manejada, pois embora primário, observa-se que o acusado possui condenação pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e, inclusive, foi liberado da fundação CASA poucos dias antes de sua prisão. De se ressaltar que eventual condição de usuário do acusado, por si, não tem o condão de afastar as ilações ora tomadas, eis que as particularidades da ação criminosa e as circunstâncias da prisão justificam a responsabilização pelo crime de tráfico.

Aliás, a rotina forense demonstra que muitos usuários acabam praticando o comércio espúrio para viabilizar a manutenção do próprio consumo, devendo responder pela conduta mais grave, como vem pacificamente entendendo a Egrégia Corte Bandeirante: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP, 101/498);

"Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio." (TJSP - AC 896.821.3/8-00, Rel. René

Ricupero J. 30.11.2006).

O fato de não ter sido o inculpado flagrado efetuando, propriamente, a comercialização de entorpecente não compromete a materialização do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Como se sabe, o tipo penal em análise constitui delito de ação múltipla ou conteúdo variado, perfazendo-se com a realização de qualquer dos verbos nele descrito, os quais não se encontram submetidos a regime cumulativo.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente."(RT 584/347).

Na hipótese, consoante já exaustivamente explanado, o acusado tinha em depósito grande quantidade de substância ilícita, evidenciando o contexto que o tóxico seria entregue ao consumo de terceiros.

Encerrando a tipificação, com o devido respeito ao entendimento do I. Defensor, sublinho que a causa de diminuição de pena trazida pelo § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, não se mostra aplicável na espécie ao réu, pois conforme demonstrado pela prova oral colhida, o acusado praticava o tráfico de forma reiterada e habitual e, inclusive, haviam diversas denúncias em seu desfavor.

No mais, além de ser conhecido nos meios policiais como traficante, fato narrado pelos policiais ouvidos em juízo, o acusado apresenta envolvimento com a venda de entorpecentes desde a sua adolescência e, inclusive, foi condenado ao cumprimento de medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (fl. 46).

Vale salientar que a condenação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico não pode ser considerada como antecedente criminal e, tampouco, para fins de reincidência, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores. Entretanto, a condenação pela prática do ato infracional recente é suficiente para demonstrar o envolvimento reiterado do acusado com o tráfico de entorpecentes e, portanto, afastar o benefício previsto no art. 33, §4 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o agente dedica-se às atividades criminosas de forma habitual e reiterada desde a sua adolescência.

Nesse sentido, seguem abaixo julgados do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (AgRg no HC n. 559.155-sp, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) (grifei).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades

criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.560.667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) (grifei).

Desse modo, apreciadas as teses levantadas por acusação e defesa, não incidindo causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a procedência dos pedidos formulados, com a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, pois, a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais, tanto as genéricas, veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal, como as específicas para o delito em análise, insculpidas no artigo 42, da Lei de Tóxicos. Nesse mister, inobstante primário, o réu trazia consigo grande quantidade de cocaína e crack, substâncias altamente viciantes e aptas a promoverem a rápida degradação física e psíquica do usuário, conjuntura que imprime elevado grau de censurabilidade à sua conduta perpetrada. Desse modo, pela quantidade e natureza das drogas traficadas, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a pena intermediária em 1/6 obtendo o total de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 555 dias-multa.

Ausentes causas de aumento de pena. Não incidem causas de redução de pena, valendo registrar que a dedicação às atividades criminosas de forma habitual e reiterada, conforme demonstrado pela certidão de fl. 46, afasta a incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o reconhecimento do privilégio exige, dentre outros requisitos, que o agente não se dedique às atividades criminosas. Vale ressaltar que, embora primário, o acusado ostenta condenação pela prática de ato infracional coetâneo ao crime objeto destes autos, o que demonstra o envolvimento habitual e reiterado do sentenciado com o comércio de entorpecentes, desde a sua adolescência.

Inexistindo nos autos elementos que forneçam parâmetros seguros para a aferição da condição econômica do réu, fica o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Sem confrontar posicionamento recentemente adotado pelo C. STF (habeas corpus nº 97.256/RS, cujos efeitos foram ampliados pela Resolução nº 5/2012, do Senado Federal), diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, máxime as previstas na legislação especial, o que, inclusive, deu azo à majoração da pena-base, reputo inviável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a substituição condicional da pena, considerada a inteligência dos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal.

Aqui, releva repisar que o réu foi surpreendido trazendo consigo grande quantidade de cocaína, além de 03 porções de crack, substâncias, conforme já assinalado, dotadas de alto grau de nocividade.

Referida conduta, legalmente definida como hedionda, desencadeia catastróficas consequências sociais, já que a disseminação das drogas, além de representar grande prejuízo individual ao consumidor, dá ensejo, inegavelmente, à ocorrência de diversos outros crimes, especialmente os patrimoniais, alarmando a população.

Não se mostra exagerado afirmar que o traficante, buscando lucro fácil, explora a degradação humana, aproveitando-se da fissura do usuário que, como sabido, não mede esforços para suprir a necessidade de acesso ao "produto" oferecido.

O "freguês", destarte, é presa fácil para o mercador do tóxico, resultando dessa desigual e injusta interação problemas de saúde e segurança públicas de dimensões incommensuráveis.

Nesse cenário, a ação perpetrada, diante de sua gravidade concreta, merece resposta penal enérgica e exemplar, sendo certo que a aplicação de simples pena alternativa, ou a suspensão da pena, geraria na sociedade grande sensação de insegurança, além de criar no próprio réu sentimento de impunidade, o que o estimularia a prosseguir violando a lei penal.

O delito imputado ao acusado é equiparado pela Lei aos crimes hediondos e, assim, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá a pena privativa de liberdade imposta ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, observando-se a fração para progressão estabelecida na hipótese. Em observância ao entendimento esposado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus n.º 111.840 (Rel. Min. Ministro Dias Toffoli, j. 27.6.2012), registre-se que, diante das ilações tecidas nos parágrafos supra, regime diverso não se mostraria suficiente para a punição da conduta, reiterada a subsistência de circunstâncias judiciais especiais desfavoráveis. Destaco, encerrando, que a regra constante da nova redação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, não conduzirá à alteração do regime inicial de cumprimento, fixado em função das circunstâncias judiciais especiais desfavoráveis, e não do montante da reprimenda corporal, cumprindo anotar que a regra em testilha não autoriza o juízo do conhecimento a realizar progressão de regime, atribuição exclusiva do juízo das execuções (artigo 66, III, "a", da Lei 7.210/84).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar GUSTAVO PORFÍRIO DA SILVA, portador da cédula de identidade R.G. nº 52.695.606/SP, filho de Valdir Porfírio da Silva e Claudete Aparecida da Silva, devidamente qualificado nos autos (fl. 10), como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 555 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A multa deverá ser paga em dez dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto, à luz da nova redação dada ao artigo 313, do Código de Processo Penal, pela Lei 12.403/2011, impõe-se a manutenção da prisão, ficando agora reiterados os fundamentos expostos na r. decisão de fls. 69/72, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em acréscimo, não se pode ignorar que deverá o increpado iniciar o cumprimento de sua pena corporal em regime fechado, de modo que sua libertação nesse momento processual seguramente comprometeria a aplicação da Lei Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Caso haja recurso de qualquer das partes, expeça-se guia de recolhimento provisório, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, na forma do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 11.343/06. Restando evidente o nexo etiológico entre o numerário constrito nos autos (fl. 90) e a prática do tráfico, não tendo o réu logrado demonstrar a origem lícita do dinheiro, com fundamento na inteligência do artigo 91, II, "b", do Código Penal, decreto sua perda em favor da União, devendo ser revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Com fundamento na inteligência do artigo 91, II, "a", do Código Penal, tratando-se de inequívocos instrumentos do crime, decreto a perda em favor da União de todos os demais bens apreendidos nos autos (vide fls. 11/12), os quais deverão ser vendidos pela SENAD, nos termos do artigo 63, § 2º, da mesma Lei.

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o(s) delito(s) praticado(s) não possui vítima certa.

Custas na forma da Lei.

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do artigo 63, § 4º, da Lei 11.343/06, com relação aos bens e valores declarados perdidos em favor da União,



oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA